

1501411-13.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sandra Regina Nostre Marques

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... Pereria Malaquias Filho, em conduta típica de tráfico de drogas. Afirmou que o adolescente, aparentemente, atuava como olheiro do ponto de tráfico de drogas, na medida em que realizava a triagem de pessoas que ali compareciam. Ato contínuo, o adolescente indicava às pessoas que ali chegavam que prosseguissem até uma viela, sendo que até então a equipe não tinha contato ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, . - Vila Tereza

CEP: 09606-000 - São Bernardo do Campo - SP

Telefone: (11) 2845-9585 - E-mail: saobernardo1cr@tjsp.jus.br

1501411-13.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501411-13.2021.8.26.0537 controle nº2021/001097

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MIKAEL MATHEUS DA SILVA TEIXEIRA

CONCLUSÃO:

Aos 08 de março de 2022, faço os presentes autos conclusos à Exma. Sra. Dra. SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES, MM. Juíza de Direito. Escrev.:.

Autos digitais controle nº 1097/2021

Vistos.

MIKAEL MATHEUS DA SILVA TEIXEIRA, qualificado a fls. 19, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do art. 33, "caput" c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque em 15 de julho de 2021, por volta de 13 horas e 50 minutos, na Travessa Projetada, nº indeterminado, bairro Centro, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, o réu, previamente ajustado, com unidade de desígnio e identidade de propósitos com o adolescente Dione Pereira Malaquias Filho, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para fins de comercialização, drogas, consistentes em 35,99 gramas de cocaína acondicionadas em 52 eppendorfs; 66,04 gramas de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, acondicionados em 44 invólucros plásticos; e 635 mililitros de lança perfume, acondicionados em 44 microtubos, substâncias estas que causam dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, laudo de constatação provisório de fls. 33/35 e fls. 152/154 (exame químico toxicológico - maconha e cocaína) e fls. 171/172 (exame químico toxicológico - lança perfume). Segundo o apurado, na data dos fatos, o denunciado e o adolescente Dione se

ajustaram para a comercialização de drogas. Para tanto, o denunciado guardou em sua residência quarenta e quatro tubos de lança-perfume, vinte porções de maconha e vinte porções de cocaína no interior de uma caixa de pizza e se dirigiu à Travessa Projetada, na companhia do adolescente, em poder de seis porções de maconha e duas porções de cocaína, acondicionadas em uma sacola plástica. Na mesma data, policiais civis se dirigiram ao local dos fatos, onde há conhecido ponto de comercialização de drogas e, ao visualizarem a dupla em atitude suspeita, iniciaram breve campanha. Durante observação, os agentes públicos visualizaram o adolescente atuando na função de "olheiro", isto é, além de vigiar a eventual chegada de policiais, ele ainda recebia os usuários e os encaminhava ao local onde o denunciado estava. Diante da fundada suspeita acerca da comercialização de drogas, os policiais desembarcaram da viatura e realizaram a abordagem. Ao notar a aproximação dos policiais, o adolescente empreendeu fuga do local e alertou o denunciado, que igualmente fugiu e ainda dispensou uma sacola plástica no chão, onde, posteriormente, foram encontradas 06 porções de maconha e 02 porções de cocaína. Após breve perseguição, o denunciado e o adolescente foram abordados. No bolso de MIKAEL, os policiais encontraram a quantia de R\$31,00 (trinta e um reais), fruto da comercialização ilícita de entorpecentes.

Na ocasião, MIKAEL levou os policiais civis até uma viela, onde foi encontrada uma pochete na cor azul, contendo 18 (dezoito) porções de maconha, 30 (trinta) porções de cocaína e 02 folhas com anotações de contabilidade do narcotráfico.

Como o denunciado não portava documento de identidade, os policiais o acompanharam até sua residência, onde foram localizadas mais drogas, isto é, 44 (quarenta e quatro) tubos de lança-perfume, 20 (vinte) porções de maconha e 20 (vinte) porções de cocaína acondicionadas em uma caixa de pizza vazia.

Indagado informalmente, o denunciado assumiu a comercialização de drogas e revelou que recebia 10% do produto do crime. Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante e o adolescente, apreendido, sendo ambos conduzidos à delegacia de polícia.

Considerando a significativa quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, a sua forma de acondicionamento - em embalagens individuais, prontas para a venda e consumo de terceiros, a breve campanha realizada pelos policiais e a apreensão de valores em dinheiro com o denunciado, produto da mercancia ilegal, não há dúvidas de que as substâncias entorpecentes se destinavam ao comércio ilícito.

Foram arroladas duas testemunhas pela acusação, que instruiu a denúncia com o inquérito policial de fls. 05/79.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela decisão de fls. 44/46, cujo mandado se encontra juntado a fls. 80/82.

Pela decisão de fls. 80/81 foi determinada a notificação do denunciado, dentre outras providências.

Laudos encontram-se juntados às fls.37/39 (constatação), fls.108/109 (bolsa), fls.110/111 (papel com anotações), fls.152/154 (exame químico toxicológico - maconha e cocaína) e fls. 171/172 (exame químico toxicológico - lança perfume) e fls. 167/168 e 169/170 (exame de corpo de delito do réu).

A folha de antecedentes federal acha-se juntada a fl.116. Certidão SGC:

fls.105/107. A folha de antecedentes do SIVEC acha-se juntada às fls. 44/46.

Comprovante de depósito de valor apreendido encontra-se juntado às fls. 114/115.

Regularmente notificado dos termos da inicial em 16.11.2021 (fl.122), mesmo tendo Defensor constituído à fl.88, não ofereceu defesa preliminar, o que veio a ser suprido pela Defensoria Pública que ofertou defesa sem arguir preliminares (fl.140).

A denúncia foi recebida pela decisão de fls.143/144 (em 31.01.2022).

O réu foi citado pessoalmente (fl.165).

Em audiência, ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, seguiu-se com o interrogatório do réu. Após, as partes debateram oralmente. O Ministério Público sustentou pedido de condenação do réu nos moldes da denúncia, enquanto a defesa, requereu a absolvição do réu alegando insuficiência probatória. Alternativamente, requereu reconhecimento de atenuante da confissão espontânea, bem como a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/06, assim como outras

benesses legais.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitativa evidencia-se pelo auto de apreensão de fls. 17/18 (pochete, celular, anotações de tráfico, dinheiro e drogas), assim como pela juntada dos laudos de fls.37/39 (constatação), fls.108/109 (bolsa), fls. 110/111 (papel com anotações), fls. 152/154 (exame químico toxicológico - maconha e cocaína) e fls. 171/172 (exame químico toxicológico - lança perfume).

A autoria, por outro lado, restou comprovada.

O réu, ouvido na fase inquisitorial (fl.16), preferiu manter-se em silêncio.

Ouvido em Juízo, declarou que no dia dos fatos foi para o local dos fatos por volta das 11h da manhã para vender as drogas, e que enquanto estava traficando, servindo uma pessoa, os policiais chegaram. Disse que quando viu os policiais, correu com uma bolsa azul nas mãos onde estavam as drogas. Disse que ficou escondido na passarela, perto da rodovia Anchieta. Disse que um dos policiais o abordou e, então, confessou que estava traficando, mostrando ao policial onde estava a bolsa azul, bem como informou que havia mais drogas em sua casa. Relatou que após sua indicação, os policiais encontraram a bolsa azul, sendo que na sequência revelou que em sua residência tinha mais drogas, em uma caixa de pizza. Justificou seu ato afirmando que estava com o aluguel atrasado e no desespero pediu um valor emprestado para um agiota. Contudo, quando chegou o dia de pagar a quantia que tinha tomado emprestada, não havia conseguido o valor, então resolveu traficar para pagar o agiota. Disse que uma pessoa marcava um lugar para ele pegar as drogas e depois de vendê-las, deixava os entorpecentes restantes no mesmo lugar. Afirmou que receberia 10% (dez por cento) do valor das vendas e mais R\$ 300,00 por guardar a droga em sua casa. Disse que conheceu o menor de idade no dia de sua prisão e que o adolescente não estava na função de olheiro, bem como não o conhecia. Admitiu que já foi condenado por roubo e estava em regime aberto. Não conhecia os policiais que efetuaram sua prisão. (gravação audiovisual no SAJ).

Em que pesem as declarações do acusado, é certo que as provas colhidas autorizam sua condenação, senão vejamos.

A testemunha JOÃO BUZZÉRIO GONÇALVES, policial civil, quando ouvido na fase inquisitorial declarou que juntamente com o investigador de polícia Ronaldo, prosseguiu até à rua Projetada, próximo à rua Maria Adelaide Lima Quelhas, bairro DER, sendo que, com emprego de viatura descaracterizada permaneceu de campana por trinta minutos, quando avistou o adolescente Dione Pereria Malaquias Filho, em conduta típica de tráfico de drogas. Afirmou que o adolescente, aparentemente, atuava como olheiro do ponto de tráfico de drogas, na medida em que realizava a triagem de pessoas que ali compareciam. Ato contínuo, o adolescente indicava às pessoas que ali chegavam que prosseguissem até uma viela, sendo que até então a equipe não tinha contato visual com o destino das pessoas que ingressassem no interior. Então, no melhor momento, juntamente com o investigador de polícia Ronaldo, desembarcou da viatura e prosseguiu em direção ao adolescente, com o fim de realizar a abordagem. No entanto, o adolescente Dione empreendeu fuga a pé e ainda alertou o outro traficante de drogas, posteriormente identificado como Mikael Matheus da Silva Teixeira. Durante a fuga, Mikael dispensou um saco plástico a verificar-se, posteriormente, haver drogas no interior daquele. Solicitou apoio de outras equipes, pois havia perdido contato visual com o adolescente e Mikael, os quais se homizaram em meio a vielas na favela. Com o apoio de outras equipes, conseguiu localizar Mikael e o adolescente Dione próximo a uma passarela sobre a rodovia Anchieta. Ao ser perguntado, Mikael afirmou que, de fato, estava traficando drogas. Então, Mikael prosseguiu com a equipe até o local onde se iniciou a perseguição. No interior da sacola que Mikael havia dispensado foram localizadas seis porções de maconha e duas de cocaína. No bolso de trás de Mikael foi encontrado o valor de R\$31,00 (trinta e um reais) oriundos do tráfico de drogas. Mikael ainda disse que o adolescente era, de fato, o campana ou olheiro. Como não portava seu documento de identidade, a equipe diligenciou até à residência de Mikael, sendo que este afirmou haver mais drogas no corredor daquela. Foi, então,

encontrada uma sacola contendo quarenta e quatro tubos de lança-perfume, vinte porções de maconha e vinte porções de cocaína. Afirmou que as drogas estavam homiziadas no interior de uma caixa de pizza vazia. Afirmou, ainda, que Mikael afirmou dedicar-se ao tráfico de drogas há cerca de duas semanas e que foi aliciado pela pessoa de prenome Caio, igualmente, morador do bairro DER, tendo sido, ainda, que recebia 10% (dez por cento) do valor sobre a venda de entorpecente, sendo que, inclusive, em data anterior, equipes do GOE DEIC-SBC tentaram realizar outra abordagem no mesmo ponto de tráfico de drogas. Disse, também, que equipe diligenciou até à residência do adolescente, pois, igualmente, não portava seu documento de identidade, mas nada foi encontrado, nem o documento de identidade do adolescente, sendo que pessoas conhecidas da mãe daquele se prontificaram a comunicá-la, pois o adolescente não soube informar o telefone da mãe (fls.12/13). Em juízo, o policial João Buzzério Gonçalves, ratificando as declarações anteriores, afirmou que no dia dos fatos estavam fazendo uma repressão ao tráfico no bairro do DER e nesse dia com uma viatura descaracterizada fizeram uma breve campana. Durante a observação viram um adolescente parado na rua Projetada e verificaram que pessoas chegavam perto dele e ele indicava para elas entrarem em uma ruazinha, de modo que imaginavam que ele era um olheiro. Ficaram esperando para ver se alguém saía dessa rua e conversava com o adolescente. Ficaram lá por 30 minutos e como ninguém saía do local, resolveram ir até o adolescente, de modo que combinaram que ele abordaria o adolescente, enquanto o parceiro iria entrar nessa ruazinha. Quando se aproximaram, o adolescente correu gritando "polícia, polícia", sendo que quando correram atrás dele, viram que ele estava acompanhado por um rapaz que tinha um saquinho na mão, o qual foi por ele dispensado durante a fuga, que foi coletado, sendo encontrado em seu anterior parte das drogas (maconha e cocaína). Contudo, o réu e o adolescente conseguiram fugir. Então, pediram apoio e outras viaturas, sendo que passaram a fazer uma varredura na comunidade, de modo que conseguiram localizá-los. Ao ser abordado, o réu confessou que onde ele estava havia uma pochete com mais drogas. Como o réu estava sem documentos, foram até a sua residência e lá ele informou que havia mais drogas dentro de uma caixa de pizza, bem como lança perfume. Encontraram a pochete onde ele indicou e dentro dela havia drogas e contabilidade. Com o réu encontraram dinheiro. Dentro da caixa de pizza encontrada junto a entulhos no interior do quintal da casa dele havia cocaína, maconha e lança perfume. O réu admitiu que estava traficando, tendo ele ainda admitido que contava com o auxílio do adolescente nessa tarefa (gravação audiovisual no SAJ).

Já o policial civil RONALDO VILLAS BOAS, quando ouvido pela Autoridade Policial, declarou na data dos fatos, com uso de viatura descaracterizada, prosseguiu até o cruzamento da travessa da rua Projetada com Maria Adelaide Lima Quelhas, bairro DER, cidade de São Bernardo do Campo, onde ocorre o tráfico de drogas. A equipe permaneceu de campana por cerca de trinta minutos, quando avistou o adolescente Dione Pereira Malaquias Filho, na função de campana ou olheiro. A equipe não tinha contato visual com o "vapor", isto é, aquele que atua diretamente na venda de drogas. Assim, no melhor momento, a equipe desembarcou da viatura para realizar a abordagem, quando o adolescente empreendeu fuga e ainda alertou o "vapor", posteriormente identificado como Mikael Matheus da Silva Teixeira. Durante a fuga, Mikael dispensou uma sacola plástica com drogas. A equipe perdeu contato visual com os suspeitos, sendo necessário pedido de apoio para localizá-los. Então, Mikael e o adolescente Dione foram encontrados próximos à uma passarela sobre a Rodovia Anchieta. Mikael trazia consigo a importância de R\$31,00 (trinta e um reais) oriundos do tráfico de drogas, tendo ele admitido que o adolescente era campana ou olheiro. Foram realizadas diligências na residência de Mikael, pois não portava qualquer documento de identidade. Ali foram localizadas mais drogas no interior de uma caixa de pizza vazia no quintal. Foram providenciadas diligências na residência do adolescente com o fim de comunicar a detenção daquele à mãe, assim como encontrar seu documento de identidade, porém, a mãe do adolescente, tampouco seu documento foram encontrados (fl.14).

Em Juízo, a testemunha Ronaldo Villas Boas, policial civil, declarou que no dia dos fatos ele e o companheiro de trabalho foram para a comunidade do "DER" e passaram a

observar por cerca de trinta minutos a rua Projetada, local conhecido de tráfico de drogas, momento em que viram que o adolescente Dione recebia pessoas e encaminhava-as para dentro de uma viela. Como não conseguiam ver para onde ele encaminhava aquelas pessoas, a equipe policial resolveu se aproximar. Quando se aproximaram, o adolescente correu, juntando-se ao réu na viela, sendo acabaram por se evadir juntos. Durante a fuga o réu dispensou uma sacolinha plástica com porções de maconha e cocaína. Pediram apoio a outras viaturas e conseguiram localizar os dois, o adolescente e o réu Mikael, encontrando-os após cerca de quinze a vinte minutos, escondidos perto da rodovia Anchieta. Abordados eles confessaram que estavam praticando tráfico. Afirmou que Mikael admitiu que tinha sido ele quem se evadira da viela e que ele ali estava vendendo as drogas há duas semanas, sendo que o adolescente o auxiliava, exercendo a atividade de "olheiro". Mikael disse aos policiais que na viela onde ele estava havia uma pochete com as drogas. Foram ao local por ele indicado e encontraram porções de maconha e de cocaína, além de anotações do tráfico e valores em dinheiro. Com ele já tinham encontrado a quantia de trinta e um reais aproximadamente. Como ele estava sem documento, a equipe foi até a casa dele. O réu, então, admitiu que em sua residência havia mais drogas, indicando o local. Tratava-se de uma caixa de pizza jogada no quintal, dentro da qual foram encontradas mais drogas, tais como cocaína, maconha e inclusive lança perfume. Não conhecia o réu anteriormente (gravação audiovisual no SAJ). Assim, como se vê, as provas colhidas no decorrer da instrução autorizam a condenação do réu. É certo que os depoimentos dos policiais demonstram que a acusação tal qual colocada na denúncia espelha o que de fato ocorreu naquele dia. E, no caso, os depoimentos dos policiais não podem ser afastados, seja porque eles não conheciam o réu, seja porque não estão impedidos de depor, de modo que não haveria qualquer motivo para que falsamente mudassem a versão dos acontecimentos para prejudicar quem quer que seja.

Não custa lembrar o quanto decide a jurisprudência acerca da validade do depoimento dos policiais:

"É inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372).

"Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no Código de Processo Penal determinando que a Polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição" (RT 654/278).

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade: O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1ª Turma - HC nº 74.608-0/SP, rel. Ministro Celso de Mello - DJU 11.04.97, pág. 12.189).

E desses depoimentos restou demonstrado que o réu, juntamente com o adolescente, dirigiram-se ao local para efetuar o comércio ilícito de drogas. O adolescente permanecia à espreita dando apoio à venda que era concretizada pelo réu. Os policiais visualizaram o adolescente recebendo as pessoas que se aproximavam da entrada da viela e resolveram se aproximar para abordagem, momento em que o adolescente correu em direção à viela e avisou o réu que ali estava sobre a chegada dos policiais. O réu, então, dispensou uma pequena sacola que trazia consigo, que

foi apreendida pelos policiais, na qual havia porções de cocaína e maconha. Ele e o adolescente conseguiram fugir. Porém, acabaram sendo encontrados juntos pouco tempo depois. Ambos admitiram que faziam a traficância naquele local onde foram avistados inicialmente, sendo que com o réu encontraram dinheiro. Então, ao ser questionado sobre a existência de mais drogas, o próprio réu indicou o local onde elas estavam escondidas naquela viela. Então, foram à viela e encontraram uma pochete dentro da qual havia mais porções de maconha e cocaína, além de papéis com contabilidade de drogas. Por fim, foram à residência do réu, que estava sem documentos, local em que por indicação do próprio réu, encontraram dentro de uma caixa de pizza junto a entulhos no quintal da casa dele, mais porções de maconha, cocaína e porções de lança-perfume. Essa foi a dinâmica dos acontecimentos.

E, como se pode observar, os depoimentos dos policiais, que são insuspeitos, não foram desmentidos por nenhum outro elemento de prova, como já ressaltado, sendo eles harmônicos entre si, de modo que não restam dúvidas de que o réu trazia consigo as drogas (as que estavam na sacola por ele dispensada durante a fuga), guardava-as (aquelas que estavam na pochete azul) e tinha-as em depósito (as drogas encontradas em sua residência escondidas dentro da caixa de pizza), as quais acabaram apreendidas, assim como o produto do ilícito (o dinheiro).

E, certamente, a quantidade e a forma de acondicionamento, em pequenas porções individuais prontas para comercialização, bem como a localização de dinheiro, além das demais circunstâncias que envolveram a sua prisão, assim como o local onde foi abordado, onde costumeiramente ocorre o tráfico de drogas, assim como o encontro de contabilidade da venda das drogas, indicam que a posse das drogas visava à comercialização e entrega a consumo de terceiros.

Outrossim, no caso, ao contrário do alegado pelo réu, não restam dúvidas que o ato ilícito envolvia o adolescente Dione, tal qual posto na denúncia, eis que ele, conforme relato dos policiais civis que realizaram campanha no local descrito na denúncia, fazia a função de olheiro, ou seja, ele orientava os usuários que chegavam para comprar os entorpecentes e se mantinha alerta para avisar seu comparsa caso a polícia aparecesse no local. Ora, se o adolescente fosse mero usuário como alegado pelo réu, não haveria motivos para ter corrido na companhia do réu e muito ter se mantido em sua companhia quando foram abordados por policiais algum tempo depois.

Dessa forma, a conduta do réu amolda-se à figura típica definida no art. 33

"caput", c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11343/06.

Dessa forma, passarei à dosagem de sua pena à luz do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11343/06.

Não se pode desconsiderar a quantidade (cento e quarenta porções individuais) e variedade das drogas apreendidas (maconha, cocaína e lança-perfume). A cocaína é reconhecidamente uma das variedades de drogas que causa dependência de forma mais rápida e, por conseguinte, que mais prejuízo traz à saúde pública, que é o bem jurídico tutelado. Assim, para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime de tráfico de drogas, fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Observo que o réu é reincidente, como faz prova a certidão de fls. 41/43 (autos nº 4034-19/2016, deste Juízo), eis que já se viu condenado por crime de roubo qualificado. Assim, aumento a pena do réu de 1/6 (um sexto), totalizando, 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do acusado como requerido pela defesa, haja vista que sua confissão foi parcial e, naquilo que confessou, não encontrou respaldo na prova colhida. Apenas visou assumir toda a responsabilidade visando isentar o comparsa de qualquer culpa, o que, como se viu, não ocorreu.

E, segundo já decidido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, "Confissão espontânea parcial da prática delitiva. Atenuante não caracterizada. Não se caracteriza a atenuante da confissão espontânea se o acusado admite apenas parcialmente a prática delituosa" (Apelação Criminal nº 0016468-33.2017.8.26.0361, da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, relator

Desembargador GRASSI NETO, julgado e publicado em 12.08.2020).

Tendo em vista o reconhecimento da causa de aumento definida no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, aumento a pena retro de 1/6 (um sexto), totalizando 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Incabível, no caso, a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois, como já foi reconhecido outrora pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, não cabe a concessão de tal benefício àqueles que trazem consigo mais de uma centena de porções de drogas, especialmente quando foram encontrados com vários tipos de drogas, em local conhecido como ponto de venda de drogas, sem que tivesse comprovado atividade lícita a garantir-lhe o sustento, o que bem dá a dimensão do envolvimento dele com o exercício do narcotráfico com habitualidade (Apelação Criminal nº 150.0124-83.2029.8.26.0537, julgado em 08.05.2020, relator Desembargador Marco Antônio Cogan, da 8ª Câmara Criminal), o que fica mais evidente com a apreensão de contabilidade das drogas (vide fls. 110/111). Além disso, o réu é reincidente e estava em gozo de regime aberto (vide fls. 44/46), indicando que se dedica a práticas criminosas, sendo criminoso habitual.

Incabível, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/06 como requerido pela defesa, haja vista que ele não ajudou os policiais a identificar os comparsas (aliás, o réu negou envolvimento do adolescente e sequer soube indicar quem seria o responsável por lhe entregar as drogas ou efetuar o pagamento) e nem na recuperação total ou parcial do produto do crime, condições necessárias para a aplicação de tal causa de diminuição. Torno, assim, as penas definitivas ante a ausência de causas de aumento ou diminuição que as modifiquem.

Incabível, igualmente, a substituição da pena privativa de liberdade, seja em razão da quantidade de pena aplicada, seja em razão de sua incompatibilidade com a hediondez do crime e porque não se mostra suficiente e adequada para reprovar adequadamente a conduta nefasta à sociedade que exercia.

A pena deverá ser cumprida, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, no regime fechado, haja vista que o crime aqui apurado é equiparado ao hediondo. Não se pode deixar de considerar a grande quantidade de drogas apreendida em poder do agente, o que, iria atingir inúmeras pessoas, o que reclama maior punição e reprovabilidade. Assim, somente regime mais gravoso poderá, quiçá, dissuadi-los de suas vidas erráticas. Outrossim, trata-se de réu reincidente e que se encontrava cumprindo pena em regime aberto, a indicar que não está apto para conviver em sociedade. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar MIKAEL MATHEUS DA SILVA TEIXEIRA, RG nº 71.596.049, pela prática do crime definido no art. 33, "caput", c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, a 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Fixo a unidade da pena pecuniária, na forma do art. 43 da aludida lei, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, valor que deverá ser corrigido desde o crime, quando da execução.

O réu foi preso em flagrante, tendo permanecido custodiado durante toda a instrução. Não faz jus a recorrer em liberdade, até porque ainda se acham presentes os motivos autorizadores de sua prisão preventiva. Ademais, é de ressaltar que "(...) não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF - HC 89824/MS - Primeira Turma - Rel. Min. Ayres Britto - DJe: 28.08.2008). Outrossim, trata-se de réu reincidente e que estava em gozo de regime aberto, a indicar que não faz bom uso da liberdade. Assim, recomende-se o estabelecimento prisional em que se encontra, nos termos do § 1º do artigo 387 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, incabível a modificação do regime neste momento processual, eis que não há condições de se aferir a conduta carcerária do acusado, requisito subjetivo para a concessão de eventual progressão (art. 112 do LEP). Além disso, não há certeza que a pena ora aplicada será a definitiva, eis que é passível, ainda, de recurso por parte do Ministério Público, o que poderá modificar o cálculo para a

eventual progressão. Eventual progressão há de ser resolvida no Juízo das Execuções Criminais. Observo que o réu estava cumprindo pena quando praticou o novo delito, o que há de ser considerado para eventual progressão.

Decreto a perda do dinheiro apreendido (fls. 17/18 e 70/72) a favor da União, na forma do art. 91, inciso II, alínea "b" do Código Penal, devendo ser revertido ao FUNAD (art. 63, § 1º da Lei nº 11.343/06), eis que proveniente do tráfico de drogas.

Transitada em julgado a presente decisão, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados, expedindo-se, então, ofício ao SENAD informando do valor que foi declarado perdido a favor da União, nos termos do art. 63, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Observo que já foi determinada a autorização para a incineração da droga apreendida, devendo ser mantida eventual quantidade para contraprova até o final do processo (vide fls. 57/60).

Arcará o réu, na forma do art. 804 do Código de Processo Penal, bem como das despesas processuais, caso perca a condição de beneficiário da Assistência Judiciária gratuita dentro do prazo legal.

P.R.I.C.

São Bernardo do Campo, 08 de março de 2022.

SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA